

1006558-69.2022.8.26.0302

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Práticas Abusivas

Magistrado: Guilherme Eduardo Mendes Tarcia e Fazzio

Comarca: Jaú

Foro: Foro de Jaú

Vara: 4ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 02/09/2022

... segundo Couto e Silva, a base do tráfico jurídico, a base de todas as vinculações jurídicas, o princípio máximo das relações contratuais. A boa-fé objetiva e a função social do contrato são, na expressão de Waldírio Bulgarelli, 'como salvaguardas das injunções do jogo do poder negocial'. (...) Como ensinam os doutrinadores europeus, fides significa hábito de firmeza e de coerência de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jaú

Foro de Jaú

4ª Vara Cível

Avenida Rodolpho Magnani, s/n, Jaú - SP - cep 17210-100

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1006558-69.2022.8.26.0302 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1006558-69.2022.8.26.0302

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Práticas Abusivas

Requerente:

Sueli de Oliveira Coelho Jau Me

Requerido:

Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Guilherme Eduardo Mendes Tarcia e Fazzio

Vistos.

A parte autora ajuizou a presente ação objetivando condenação à "obrigação de fazer consistente no restabelecimento integral da conta @extinjau\_ ao status quo anterior à indisponibilização indevida, ocorrida em 02.06.2022 com todas as publicações, seguidores, curtidas, comentários e demais características" e indenização por danos morais.

Citada, a parte requerida apresentou resposta.

Réplica da parte autora.

É o relatório. Fundamento e decido.

Julgamento do processo no estado, tratando-se de matéria de direito.

"Tendo o Magistrado elementos suficientes para o esclarecimento da questão, fica o mesmo autorizado a dispensar a produção de quaisquer outras provas, ainda que já tenha saneado o processo, podendo julgar antecipadamente a lide, sem que isso configure cerceamento de defesa" (Código de Processo Civil e legislação processual em vigor - Theotônio Negrão - Ed. Saraiva - 31a ed. -pág. 397).

No exercício jurisdicional de aplicação da lei e do direito, mediante independência

funcional, persuasão racional e livre convicção, diante da análise dos fatos, dos fundamentos jurídicos e de toda a prova contida nos autos, em meu convencimento, prospera em parte o pedido, pese o respeito pelos doutos entendimentos diversos.

Como salientado na inicial, não obstante o Instagram constitua uma plataforma de rede social, constitui um aplicativo de interação entre os usuários que está submetido a adesão contratual que estabelece termos de uso cuja infração pode implicar na exclusão ou limitação de acesso.

Nestes termos, pertinentes as extensas pontuações da parte requerida expostas nos itens do "exercício regular de direito do Instagram e princípio da obrigatoriedade dos contratos" e "dos limites da intervenção do Estado na atividade econômica e impossibilidade de compelir o Facebook a permanecer contratado - arts. 1º, IV, e 170 da Constituição Federal".

Ainda como salientado pela parte requerida:

"25. Logo, quando o Instagram toma medidas de remoção de conteúdo, indisponibilidade de uma conta ou bloqueios, o que se tem em mente é a proteção do quanto disposto nos Termos de Uso e Diretrizes da Comunidade, haja vista que o Provedor de Aplicações do Instagram se compromete com seus usuários a oferecer um ambiente harmônico, respeitoso e seguro.

26. Ademais, nos Termos de Uso do serviço Instagram há previsão expressa quanto à necessidade de observância às regras estabelecidas nos Termos e Diretrizes do serviço, bem como quanto à possibilidade de exclusão de conteúdos e/ou contas, restrições de contas que violem os referidos termos e até mesmo indisponibilidade de uma conta para eventuais averiguações que possam se fazer necessárias e também caso as contas violem os termos de Uso do Instagram.

27. Nesse sentido, repisa-se que a parte Autora, assim como todos os usuários do serviço Instagram, tem ciência inequívoca de que, ao se cadastrarem no serviço Instagram, há a garantia contratual de que os conteúdos publicados não violarão ou transgredirão direitos de terceiros. "

Entretanto, com a máxima vênia, conquanto pertinentes toda a exposição jurídica e legal, não há uma só linha a respeito do fato concreto.

Afinal, qual a violação ou abuso praticado pela parte autora que tenha constituído violação contratual ou ilícito para justificar medida de tamanha magnitude a tornar indisponível e excluir a conta e o acesso da usuária?

A parte requerida afirmou que "o Provedor de Aplicações do serviço Instagram, agiu nos exatos limites do exercício regular de direito, nos moldes do inciso I do artigo 188 do Código Civil, pois estava simplesmente cumprindo o contrato estipulado com o usuário".

Ora, qual o fato, a postagem, o compartilhamento, a mensagem ou qualquer outra conduta da parte autora na plataforma que demonstra que a parte autora "agiu nos exatos limites do exercício regular de direito"?

Qual elemento concreto dá respaldo à evidência de violação praticada pela parte autora a justificar a atuação da parte requerida "simplesmente cumprindo o contrato" para promover a suspensão, indisponibilidade ou exclusão da conta?

A parte requerida nada, absolutamente nada justificou; nenhum fato concreto.

Note-se que a parte autora pleiteia o regular cumprimento do contrato.

É a parte requerida quem aduz, como fato impeditivo ou extintivo, a existência de exceptio non adimpleti contractus para a rescisão do contrato, ou ainda, a imposição sanção contratual por suposta violação dos termos de uso - com ônus do

art. 373, II, do CPC.

Afirmou a parte autora suspensão/desativação sem qualquer justificativa ou informação.

A parte requerida não impugnou os fatos e não justificou a conduta contratual, pois não trouxe narrativa de qualquer fato que pudesse sustentar tal assertiva.

Logo, trata-se de inequívoco desatendimento do ônus da impugnação especificada, razão pela qual é presumida a veracidade da assertiva da parte autora não impugnada especificada pela parte requerida (art. 341, caput, do CPC).

Portanto, outra conclusão não há que a evidência de injustificada violação contratual pela parte requerida que, sem motivo ou justificativa (pelo menos, nestes autos nada expôs) suspendeu/desativou/indisponibilizou a conta e o acesso da parte autora na plataforma de rede social Instagram.

Em suma, pela prova dos autos, resta a evidência de ilícito contratual na cessação do cumprimento sem justificativa em grave violação da boa-fé objetiva inobservância aos deveres anexos de cuidado e informação, nos termos do art. 422 do Código Civil.

Afinal, a boa-fé objetiva impõe o dever anexo de cuidado e que “a imposição desta obrigação acessória no cumprimento do contrato tem por fim preservar o co-contratante de danos à sua integridade: 1) a sua integridade pessoal (moral ou física) e 2) à integridade de seu patrimônio. A violação destes deveres geralmente resulta em dano não só material, mas moral ao consumidor e está intrinsecamente ligada às normas do CDC para os bancos de dados” (Cláudia Lima Marques, Contratos no Código de Defesa do Consumidor, 4ª Ed., RT. pg.198/199).

Logo, devida a obrigação de fazer de restituir o status quo da parte autora em estrita obrigação de cumprir o contrato.

Considerando o tempo decorrido da suspensão em prejuízo da parte autora de forma injustificada, em análise de cognição exauriente, emerge a presença dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência para assegurar a eficácia do provimento jurisdicional pretendido – pena de impor à parte autora o ônus do tempo de duração do processo em eventual seara recursal com ampliação da extensão dos prejuízos em contrapartida de evidência do direito violado.

Por outro lado, o dano moral é inequívoco.

Como já salientado, operou-se grave violação da boa-fé objetiva pela parte requerida em inobservância aos deveres anexos de cuidado e informação.

A parte autora foi despojada de seu acesso e conta na plataforma sem qualquer apresentação de justificativa, sem qualquer comunicação prévia ou posterior e, em especial, sem qualquer oportunização de manifestação.

E, no contexto processual já salientado, ainda emerge a violação das expectativas do usuário de que a plataforma adota valores democráticos afirmando que “não existe censura no serviço Instagram”, que permite “exercício da liberdade de expressão pelos seus usuários” e que atua com “fim de promover um ambiente seguro”.

Qual segurança do ambiente do serviço o consumidor ou usuário pode esperar legitimamente se possível ser submetido a suspensão de sua conta e conteúdo produzido sem qualquer explicação, notificação, informação ou justificativa?

O mínimo esperado pelo consumidor/usuário é ser informado a respeito das razões pelas quais eventualmente teve sua suspensão/desativação.

Com a máxima vênia, a conduta contratual constitui quebra da confiança do consumidor, pois é incompatível com os valores democráticos de liberdade de expressão e a repúdio censura preconizados pela plataforma de serviços que, pela prova dos autos, adotou postura contratual de total falta de transparência ou diálogo, não se olvide, mais comum nos regimes totalitários e anti-democráticos.

Neste panorama grave a magnitude do ilícito contratual com frustração das legítimas expectativas e violação dos princípios da confiança e da boa-fé objetiva.

Novamente emerge pertinência da lição de Cláudia Lima Marques, em digressão mais ampla e profunda, a respeito da abrangência da boa-fé objetiva no cumprimento dos contratos:

“(...) boa-fé significa uma atuação 'refletida', atuação refletindo, pensando no outro, no parceiro contratual, respeitando-o, respeitando seus interesses legítimos, seus direitos, respeitando os fins do contrato, agindo com lealdade, sem abuso da posição contratual, sem causar lesão ou desvantagem excessiva, com cuidado para com a pessoa e o patrimônio do parceiro contratual, cooperando para atingir o bom fim das obrigações, isto é, o cumprimento do objetivo contratual e a realização dos interesses legítimos de ambos os parceiros. Trata-se de uma boa-fé objetiva, um paradigma de conduta leal, e não apenas da boa-fé subjetiva, conhecida regra de conduta subjetiva no Código Civil. Boa-fé objetiva é um standard de comportamento leal, com base na confiança despertada na outra parte co-contratante, respeitando suas expectativas legítimas e contribuindo para a segurança das relações negociais. Note-se que o princípio da boa-fé objetiva, princípio orientador das relações de consumo segundo o CDC (art. 4º, III), apresenta dupla função. Tem função criadora (pflichtenbegründende Funktion), seja como fonte de novos deveres (Nebenpflichten), deveres de conduta anexos aos deveres de prestação contratual, como o dever de informar, de cuidado e de cooperação; seja como fonte de responsabilidade por ato lícito (Vertrauenshaftung), ao impor riscos profissionais novos e indisponíveis. Assim também possui o princípio da boa-fé uma função limitadora (Schranken- bzw. Kontrollfunktion), reduzindo a liberdade de atuação dos parceiros contratuais ao definir algumas condutas e cláusulas como abusivas, seja controlando a transferência dos riscos profissionais e libertando o devedor face a não-razoabilidade de outra conduta (pflichtenbefreinde Vertrauensumstände). O princípio geral de boa-fé, positivado no CDC, em seu art. 4º, inc. III, estipula um mandamento de boa-fé (objetiva) a guiar todas as condutas, em especial a do fornecedor de serviços, como atividade necessariamente leal, cooperativa, informativa, transparente, cuidando do nome e patrimônio daquele que o escolheu como parceiro, os consumidores, presumidos legalmente como parte vulnerável da relação (art. 4º, I do CDC). Aqui um reflexo da função positiva do princípio da boa-fé, da força criativa de deveres de conduta, princípio que interpretando as normas positivas impõe uma atuação refletida do contratante mais forte em relação aos interesses do contratante mais fraco, o consumidor. Trata-se de mais um mandamento de proteção da segurança e da harmonia social (Vertrauensgebot), o qual imporia àqueles que exercerem atividades no mercado, suportar riscos profissionais e deveres de conduta mais elevados, a eles imputados por esta lei especial, uma vez que visam lucro (direta ou indiretamente) através desta sua atividade negocial que atinge um grande número de consumidores (indivíduos, grupo ou coletividade tutelada)” (Proposta de uma Teoria Geral Dos Serviços com base no Código de Defesa do Consumidor, Revista da Faculdade de Direito da UFRGS Vol. 18 - 2000, pág. 35)

E ainda que:

“Boa-fé é cooperação e respeito, é conduta esperada e leal, tutelada em todas as relações sociais. A proteção da boa-fé e da confiança despertada formam, segundo Couto e Silva, a base do tráfico jurídico, a base de todas as vinculações jurídicas, o princípio máximo das relações contratuais. A boa-fé objetiva e a função social do contrato são, na expressão de Waldírio Bulgarelli, 'como salvaguardas das injunções do jogo do poder negocial'. (...) Como ensinam os

doutrinadores europeus, fides significa hábito de firmeza e de coerência de quem sabe honrar os compromissos assumidos, significa, mais além do compromisso expresso, a 'fidelidade' e coerência no cumprimento da expectativa alheia independente da palavra que haja sido dada, ou do acordo que tenha sido concluído; representando sob este aspecto, a atitude de lealdade, de fidelidade, de cuidado que se costuma observar e que é legitimamente esperada nas relações entre homens honrados, no respeitoso cumprimento das expectativas reciprocamente confiadas. É o compromisso expresso ou implícito de 'fidelidade' e 'cooperação' nas relações contratuais, é uma visão mais ampla, menos textual do vínculo, é a concepção leal do vínculo, das expectativas que desperta (confiança)" (Contratos no Código de Defesa do Consumidor, RT).

Também pertinente o ensinamento da doutrinadora Judith Martins-Costa de que deve ser tida a boa-fé "como 'regra de conduta' fundada na honestidade, na retidão, na lealdade e, principalmente, na 'consideração para com os interesses do alter, visto como um membro do conjunto social que é juridicamente tutelado'. Aí se insere a consideração para com as expectativas legitimamente geradas, pela própria conduta, nos demais membros da comunidade, especialmente no outro pólo da relação obrigacional. A boa-fé objetiva qualifica, pois, uma norma de comportamento leal" (A Boa-fé no Direito Privado, Ed. RT, pg. 412).

Soma-se à isso o inequívoco transtorno gerador de sofrimento psicológico e violação da honra subjetiva por punição contratual imotivada e injustificada e os reflexos negativos à sua imagem e reputação perante os demais usuários da comunidade, em especial, ao abalo empresarial perante o mercado e o público consumidor.

No mais, o dano moral dispensa prova do prejuízo, pois é *damnum in re ipsa*.

No dizer de Sérgio Cavalieri Filho "o dano moral existe em *re ipsa*; deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de tal modo que, provada a ofensa, *ipso facto* está demonstrado o dano moral à guisa de uma presunção natural, uma presunção *hominis* ou *facti*, que decorre das regras de experiência comum" (Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo, Malheiros, p. 80).

No caso de indenização por danos morais a determinação da extensão do dano é feita por arbitramento judicial, estipulando-se quantia suficiente para compensar a vítima do dano moral experimentado.

O arbitramento judicial considera: (a) as consequências do ilícito contratual; (b) a gravidade do ilícito contratual; (c) a posição e qualificação em termos sócio-econômico-financeiros das partes envolvidas.

Por estas razões, a meu ver, é adequado, justo e condigno o valor de R\$ 10.000,00, para compensar o dano moral experimentado.

Tratando-se de dano moral, liquidado por arbitramento judicial na sentença, a correção monetária tem termo inicial na data da publicação da decisão.

Incidem juros de mora desde a data da citação, nos termos do art. 398 do Código Civil.

Dispositivo.

Diante do exposto, julgo procedente em parte o pedido para:

1... condenar a parte requerida a obrigação de fazer consistente em promover ao restabelecimento da conta @extinjau\_ ao status quo anterior de 02.06.2022 com restauração de todas as publicações, seguidores, curtidas, comentários e demais características, no prazo de 48 horas, sob pena de multa de R\$ 10 mil reais por dia

de descumprimento – deferida tutela de urgência nesta seara para determinar o imediato cumprimento da ordem judicial, promovendo-se à intimação pessoal da parte requerida nos termos do entendimento firmado na Súmula 410 do STJ (“a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”);

2... condenar a parte requerida pagar para a parte autora o valor de R\$ 10.000,00 de indenização por danos morais, valor este corrigido monetariamente a partir da data da publicação desta sentença, bem como acrescido de juros de mora legais desde a data da citação.

Pela sucumbência maior, condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor atualizado da condenação, na regra do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil, diante da duração, valor reduzido da condenação e complexidade da causa.

Resolvido o mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

P.R.I.

Jaú, 02 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA